

0001634-36.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CALVERT

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... anônimas indicando a prática do tráfico de drogas por pessoa com descrição idêntica ao do réu. O réu, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir e dispensou uma sacola sob um automóvel, sendo capturado logo adiante; disse que na sacola foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Disse que o réu teria confessado a prática do tráfico de drogas informalmente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001634-36.2017.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001634-36.2017.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudio Henrique Mendes Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Cláudio Henrique Mendes Lima, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 19.7.2017, por volta das 13hs09min, na Rua Augusto Regueiro, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de folhas 13-14, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (folha 151), o réu apresentou defesa preliminar (folhas 156-157).

Recebida a denúncia (folha 164), o réu foi citado (folha 177).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha, passando-se, por fim, ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da exordial, com afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta do réu para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (folha 2), pelo boletim de ocorrência (folhas 10-12), pelo auto de exibição e apreensão (folhas 13-14), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (folhas 16-18) e pelo laudo do exame químico toxicológico (folhas 118-120), com resultado positivo para "cocaína".

A quantidade de drogas encontrada, a forma de armazenamento e as circunstâncias do caso concreto indicam que se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros, tipificando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Ouvido em juízo, o réu confessou a posse das drogas apreendidas, afirmando que as havia escondido sob um veículo. Disse, no entanto, que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal e que as mantinha escondidas embaixo do veículo para que sua mãe não descobrisse que era usuário de drogas.

A confissão parcial do réu, ademais, está em harmonia com as demais provas coligidas nos autos.

A testemunha Otávio Benedito Venâncio Correa, ouvido em juízo, confirmou que na data dos fatos receberam denúncias anônimas indicando a prática do tráfico de drogas por pessoa com descrição idêntica ao do réu. O réu, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir e dispensou uma sacola sob um automóvel, sendo capturado logo adiante; disse que na sacola foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Disse que o réu teria confessado a prática do tráfico de drogas informalmente. Afirmou que o local é próximo a igrejas, estabelecimentos de ensino e locais destinados a prática de esportes.

Os depoimentos de policiais militares ou civis, na condição de testemunhas, deve ser considerado idôneo. Não se concebe que os agentes, sem razão aparente, pretendessem incriminar inocentes desconhecidos, de forma tão abjeta. A ilação dos agentes foi corroborada, por sinal, pela eloquente apreensão das porções de entorpecente.

Ao contrário: são testemunhas que depõem compromissadas, com presunção de veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre atos que, de ofício, foram praticados no exercício de suas funções.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 73.518, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 26.3.1996)

"PROVA - Depoimento de policial - Valor: Não demonstrando a defesa, como lhe

incumbe à luz da regra do artigo 156 do CPP, os motivos que teria o policial para, ciente da inocência do acusado, imputar-lhe falsamente a prática de crime, seu depoimento, firme e coerente naquilo que é essencial, deve ser prestigiado em detrimento da palavra do réu, principalmente quando este apresentar personalidade voltada para a prática de ilícitos penais". (Tribunal de Alçada Criminal, apelação 1.442.515/4, relator Desembargador Xavier de Souza, julgada em 29.6.2004)

Além da eloquente apreensão das drogas, os policiais foram claros ao afirmar que havia denúncias recebidas pela polícia militar apontando o réu como traficante de drogas, com a descrição precisa de suas roupas e suas características físicas.

Impossível, portanto, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que as drogas não se destinavam à entrega a terceiros, mas sim ao consumo próprio, uma vez que não está em conformidade com os elementos probatórios colhidos dos autos.

As circunstâncias do caso concreto impedem que seja acolhida a tese da desclassificação. Veja-se, primeiramente, que havia diversas denúncias que apontavam o réu como traficante de drogas.

Ademais, a quantidade de drogas encontrada não se coaduna com o uso por apenas uma pessoa em curto espaço de tempo. O réu também não apresentou justificativa plausível para a manutenção das drogas escondidas sob um veículo em local público, o que é típico da atividade do traficante que vende entorpecentes em via pública, tudo levando a conclusão de que estava efetivamente vendendo drogas.

Desta feita, a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é de rigor.

Será aplicável, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é tecnicamente primário e não há provas de que se dedicasse a atividades criminosas à época dos fatos.

Não há qualquer elemento de prova que indique que, à época dos fatos tratados no presente processo, o réu dedicava-se a atividades criminosas, não obstante as notícias que chegaram aos policiais militares.

Ademais, a quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias do caso concreto não permitem enquadrar o réu como grande traficante ou como detentor de uma rede organizada de venda de drogas, assemelhando-se ao pequeno traficante, premido pelo vício em entorpecentes ou pelas circunstâncias sociais, a quem a lei pretendeu beneficiar pela causa de diminuição de pena em relevo.

Por fim, entendo que não se aplica a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Isso porque, muito embora o local em que foram apreendidas as drogas se encontrasse a uma distância que varia entre 10 (dez) e 340 (trezentos e quarenta) metros das entidades apontadas pelo Ministério Público, o "croqui" demonstra que as entidades não se encontram num espectro de influência direta do local da prática do tráfico de drogas.

Note-se que o crime foi praticado no interior de um conjunto habitacional.

A lei prevê a causa de aumento de pena em caso de o tráfico ser praticado "nas imediações" desses locais, não especificando uma distância objetiva. Deve o julgador aplicar a causa de aumento sempre que a atividade de mercancia de drogas tiver influência direta sobre tais locais, pretendendo atingir seus frequentadores ou efetivamente o fazendo, o que não está demonstrado nos autos.

Passo à dosimetria da pena, o que faço nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e dando preponderância à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, pondero que a qualidade da droga apreendida deve ser considerada para o recrudescimento da pena-base.

Com efeito, o artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que seja considerada a qualidade da droga para fins de estabelecimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Esta determinação legal, aliada à grande elasticidade do preceito secundário do tipo criminoso do artigo 33, caput, desta lei, indica que o juiz deverá aplicar penas diferentes para os diferentes tipos de substâncias entorpecentes, de acordo com a lesividade da droga.

No sentido de apenarem-se de forma diferenciada os traficantes de acordo com a quantidade e a qualidade da droga comercializada, dando efetividade ao princípio da individualização da pena, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A despeito do sustentado pela defesa, o magistrado de primeiro grau fundamentou exaustivamente a fixação da pena base do réu acima do mínimo legal, pautando-se no art. 42 da Lei 11.343/06, observando a quantidade e natureza da droga, bem como a conduta social do acusado. Tais circunstâncias extrapolam o já previsto pelo tipo e devem ser consideradas pelo magistrado quando da fixação das penas, como disposto no supramencionado artigo, pois no presente caso extrapolam o já previsto pelo tipo.

Assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo.

Repise-se, o art. 42 da Lei 11.343/06 é expresso ao determinar que a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base”. (apelação 0001695-14.2013.8.26.0396, relatada pelo Desembargador Edison Brandão, julgada em 9.9.2014, extraído do voto relator)

No caso dos autos, com o réu foram apreendidas porções de “cocaína”, droga que pode, sem qualquer receio de erro, ser apontada como uma dentre as mais lesivas em relação àquelas que são comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, “ainda que cada organismo tenha reação diferente ao impacto das drogas, é notório que a cocaína é entorpecente de altíssimo potencial lesivo, com acentuado e devastador poder psicotrópico, que vem assolando nossa sociedade, principalmente os jovens em grave situação de dependência” (extraído do voto relator na apelação 0001695-14.2013.8.26.0396, relatada pelo Desembargador Edison Brandão, julgada em 9.9.2014).

Impossível apenar da mesma forma o agente que vende “cocaína” e aquele que vende outras drogas de potencial lesivo reconhecidamente menor. Por outro lado, deve-se apenar de forma mais branda que aquele agente que comercializa o “crack”, apontada como a droga com maior potencial lesivo.

Desta forma, em atenção à qualidade da droga comercializada pelo réu, recrudescço sua pena-base em 1 (um) ano, a qual fixo em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço a presença da circunstância atenuante consistente na menoridade relativa do réu, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, a qual acarretará na atenuação de 1/6 (um sexto) da pena, a qual

passa a 5 (cinco) anos de reclusão.

Não reconheço a presença da circunstância atenuante consistente na confissão, tendo em vista que o réu negou a traficância.

Na terceira fase da dosimetria, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/2 (metade), passando a pena a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A diminuição da pena abaixo do máximo legal se justifica pela qualidade das drogas apreendidas em posse do réu e pelas circunstâncias do caso concreto, que apontam a necessidade de maior reprimenda à sua conduta.

À mingua de outras causas modificativas, torno definitiva as penas fixadas acima.

A pena pecuniária será calculada no patamar mínimo legal, ante a ausência de dados sobre a capacidade financeira do réu.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade da pena imposta e a sua primariedade, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a imposição de regime inicial fechado prevista no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente para o cumprimento das finalidades da persecução criminal, ressaltando-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da substituição, quando presentes os requisitos legais, não obstante a vedação do artigo 44 da Lei 11.343/06.

Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas em razão da aplicação de outras penas criminais deverá ser verificada após o trânsito em julgado.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar Cláudio Henrique Mendes Lima, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso de apelação em liberdade, tendo em vista a aplicação de penas não privativas de liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03, condeno, ainda, o réu, ao pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesp. Observem-se, no entanto, as disposições do artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Mogi das Cruzes, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA